Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0836634-56.2017.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Gilson Cavalcanti Ricci
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

GILSON CAVALCANTI RICCI, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS** em face de **UNIMED - CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"b) A procedência dos pedidos, confirmando a tutela antecipada e reconhecendo a impossibilidade de excluir da cobertura o aparelho Bipap Synchrony e seus acessórios, determinando ao réu que forneça os equipamentos mencionados por tempo indeterminado, sob pena de multa diária, nos termos do art. 497 e 537 do CPC, a ser determinada por este juízo, condenando a requerida a arcar com todos os dispêndios do tratamento destinado ao requerente definitivamente;***
>
> ***c) Que julgue procedente a ação também quanto ao pedido de indenização por danos morais, a fim de condenar a Requerida ao pagamento de indenização no valor equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, que hoje equivale a R$ 28.110,00 (vinte e oito mil, cento e dez reais);***
>
> ***d) Que julgue procedente a ação também quanto à restituição do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais referentes à despesa com ambulância que o autor teve em 14 de janeiro do corrente ano, que a requerida deve pagar ao autor, com juros e***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

atualização monetária, até a data do efetivo pagamento, conforme tópico neste sentido acima".

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiário de plano de saúde mantido pela parte ré, conforme documentos que instruem a petição inicial, sendo que foi diagnosticado como sendo portador Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave - DPOC GRAVE, Síndrome de Apneia e Hipopneia do sono acentuada, hipertensão arterial, doença do refluxo gastroesofágico, asma remodelada com obstrução fixa grave, hipoxemia e hipertensão pulmonar.

Após a busca de atendimento médico especializado, foi indicado tratamento com uso contínuo do aparelho de ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY, durante a noite.

Afirma que formulou à parte ré autorização para o tratamento, tendo sido autorizado o tratamento por 02 (dois) anos.

Ocorre que, no dia 25/09/2017, a requerida suspendeu o tratamento e, ao buscar questionamento, não obteve qualquer resposta.

Aduziu que a requerida manteve o tratamento *home care* de fisioterapia e nutricionista, pois não teve alta médica, mas o principal tratamento foi suspenso, sem qualquer justificativa.

Teceu considerações sobre a importância dos tratamentos prescritos.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar à parte ré assegure à parte autora tratamento com uso contínuo do aparelho de ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY,

Na decisão de fls. 252/254, foi deferida a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize o tratamento com uso do aparelho de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY e seus acessórios, pelo tempo necessário e de acordo com a prescrição médica.

A parte ré foi citada, sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 263/284), alegando, em síntese o seguinte: 1) impugnação aos benefícios da gratuidade judiciária; 2) ausência de previsão contratual de atendimento domiciliar; 3) aduz que o atendimento domiciliar prestado ao autor é uma mera liberalidade; 4) afirma que o BIPAP é uma órtese e também está excluído expressamente da cobertura contratual; 5) sustenta que tal tratamento não está previsto no rol na ANS; 6) aduz que o tratamento de eletivo e não de urgência e emergência; 7) ausência dos requisitos para o reembolso da despesa com o transporte, visto que a opção pelo transporte privado de um nosocômio para outro não caracteriza caso de urgência e emergência, bem como o autor optou livremente por contratar serviço de transporte particular interhospitalar, sem sequer ter sido solicitado fornecimento do transporte, motivo pelo qual se mostra inexistente o direito ao reembolso da despesa; 8) alternativamente, requer que o custeio seja limitado ao valor da tabela; 9) afirma que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que inexistem danos morais a serem reparados; e 10) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 383/398.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 381).

O feito foi saneado na decisão de fls. 413/417, sendo indeferida a preliminar suscitada na contestação, bem como determinada a realização de prova pericial, cuja conclusão consta do laudo de fls. 564/571, sobre o qual as partes se manifestaram.

Na decisão de fls. 589/590 foi designada audiência de instrução e julgamento.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

Posteriormente, as partes desistiram da produção de prova oral, o que foi homologado por este juízo na decisão de fl. 599.

Às fls. 602/615, as partes apresentaram memoriais escritos.

Às fls. 616/617, a parte requerida comunicou o falecimento do autor.

Na decisão de fls 702/703 foi deferida a sucessão processual da parte autora pelos seus sucessores NELLO RICCI NETO, MARIA JULIA CAVALCANTI RICCI, NELSON CAVALCANTI RICCI, MAURA JANE RICCI TENÓRIO, ANA VIRGÍNIA CAVALCANTI RICCI, VALKIRIA CAVALCANTI RICCI MEDEIROS e FABIANA CAVALCANTI RICCI.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II. I – OBRIGAÇÃO DE FAZER

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda*.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;***
>
> ***XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;***
>
> ***XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;***
>
> ***XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;***
>
> ***XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;***
>
> ***XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".***

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico do autor, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([1]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([2]).

No presente caso, o documento de fl. 24 comprova que o autor é beneficiário de plano de saúde contratado com a parte ré.

Ademais, os relatórios e exames médicos vindos com a inicial comprovam que o requerente era portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave - DPOC GRAVE, Síndrome de Apneia e Hipopneia do sono acentuada, hipertensão arterial, doença do refluxo gastroesofágico, asma remodelada com obstrução fixa grave, hipoxemia e hipertensão pulmonar (fls. 171/173) e, foi indicado pelo médico que lhe assistia, o tratamento com uso contínuo do aparelho de ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY.

Ademais, restou incontroverso que a parte ré autorizou o tratamento por 02 (dois) anos, tendo suspendido sem qualquer justificativa.

---

[1] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.
[2] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

Não bastasse isso, o perito judicial Raphael João Zaupa Júnior (CRM-MS 10620), atestou a melhora clínica após a instituição do BIPAP, bem como sugeriu a manutenção do tratamento, cuja transcrição segue:

> ***"Para confecção do presente trabalho pericial foi realizada anamnese, exame físico, análise dos documentos médicos legais de interesse ao caso e revisão da literatura médica sendo constatado que o autor é portador Asma Remodelada, cardiopatia e apneia do sono. CID: J 45, I 42, G 47.3. No momento com melhora clinica após a instituição do BiPAP. Conforme a conduta do seu medico assistente, sugiro a manutenção do uso BiPAP, para a manutenção da sua estabilidade clinica"*** (fl. 568).

Além disso, a matéria posta a decisão já foi objeto de decisão em outros feitos, nos quais se reconheceu o dever do plano de saúde fornecer tal equipamento, como se vê do julgado a seguir transcrito, o qual refere-se especialmente sobre o equipamento indicado no tratamento do autor:

> ***"E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO POSITIVA. BIPAP. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL INTERPRETADA DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. As pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde mediante serviços de forma continuada e remunerada, subsumem-se no conceito de fornecedores, e, assim sendo, os contratos por elas firmados devem se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor. O art. 47 do referido Codex dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, não se mostrando razoável a vedação à cobertura do aparelho BIPAP apenas em razão do tratamento não estar vinculado a ato cirúrgico, isto porque, a doença da apelada pode acarretar risco à sua vida e o uso do equipamento se mostra suficiente e adequado para evitar complicações"*** ([3])

Dessa forma, a requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento solicitado pelo médico responsável pelo acompanhamento da saúde do requerente.

---

[3] **TJMS**. Apelação Cível n. 0831866-58.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Bastos, j: 27/03/2019, p: 29/03/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento com uso contínuo do aparelho de ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico da paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

II.II – DANOS MORAIS

Para que exista o dever de indenizar, como é sabido, é necessário que estejam presentes os elementos da responsabilidade civil, tais sejam: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo.

Nesse sentido são as disposições dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil vigente, que, assim dispõem:

> ***"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".***
>
> ***"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".***

Logo, provada existência da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que cause prejuízo a outrem, o responsável pela violação fica obrigado a reparar o dano causado.

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([4]).

[4] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

No caso em tela, os elementos contidos nos autos denotam a necessidade de julgamento de procedência do pedido de indenização por danos morais.

Com efeito, as provas produzidas evidenciaram a necessidade do tratamento solicitado pelo médico do autor, mas houve falha na prestação de serviço, na contramão da função social do contrato e do âmago da sua essência.

A propósito, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça deste Estado, a seguir transcrito:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR RECHAÇADA – TRANSPLANTE DE RIM – DIREITO AO REEMBOLSO DO TOTAL DAS DESPESAS – DANOS MORAIS DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA, RECURSO CONHECIDOS, RECURSO DO PLANO DE SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). No caso específico, não há como negar a cobertura do total das despesas com o procedimento (transplante de rim), uma vez que definidos os valores de reembolso mediante critérios inespecíficos cujas informações não foram devidamente repassadas ao consumidor. (...) Na hipótese, restaram configurados os pressupostos necessários à configuração dos danos de ordem moral, porquanto a injusta recusa de cobertura de plano de saúde aumentou o sofrimento do segurado, que inegavelmente ficou abalado emocionalmente diante da recusa de cobertura para que realizasse a cirurgia que necessitava transplante de rim - procedimento essencial para o restabelecimento de sua saúde (...)" ([5]).***

Ressalta-se que tal recusa indevida da cobertura do plano de saúde, ocorreu em um momento delicado na vida do autor e de seus familiares, causando-lhe diversos transtornos.

Logo, a negativa à realização do tratamento indicado para o autor causou manifesto sofrimento desnecessário ao mesmo e seus familiares/sucessores, de modo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado procedente.

---

[5] **TJMS.** Apelação n. 0800769-47.2015.8.12.0031, Caarapó, 3ª Câmara Cível, Relator(a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 12/12/2017, p: 18/12/2017.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

No presente caso não há que se falar que o dano moral se trata de direito personalíssimo, não cabendo sucessão aos herdeiros.

Com efeito, ainda que a falha na prestação do serviço tenha se dado em relação ao *de cujus*, este foi ofendido enquanto ainda era vivo, de modo que se houve lesão aos seus direitos da personalidade, o direito a reparação por esse dano moral expresso em indenização é transmitido pela via sucessória.

Trata-se do conhecido dano reflexo ou ricochete, conforme entendimento jurisprudencial:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIA. RECUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. QUANTUM DEBEATUR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de ação originariamente proposta com o fito de compelir a ré Unimed a fornecer à genitora dos apelantes medicamento quimioterápico, negado administrativamente ao argumento de ausência de cobertura, bem como a pagar-lhe indenização por danos morais. 2. No curso da demanda deu-se o falecimento da autora original por conta da moléstia grave (câncer) de que era portadora, prosseguindo a ação, pelos herdeiros, somente quanto ao pedido compensatório. Assim, cinge-se a discussão no quantum arbitrado a título de dano moral, cuja majoração é perseguida pelos recorrentes. 3. Em análise dos autos, depreende-se que a autora Marines Rodrigues dos Santos era portadora de câncer de mama estágio IV e, à época da propositura da ação, necessitava do medicamento Xeloda (Copecitobina) visando melhora de sua qualidade de vida e ganho de sobrevida, conforme descrito no laudo médico de fls. 19-20 (000015). (....)" ([6]).***
>
> ***"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação***

[6] **TJ-RJ** - APL: 00342306620118190038, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 02/05/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta. 5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). 6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares. 7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização. 8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 9. Recurso especial parcialmente provido" ([7]);

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. LEGITIMIDADE DOS PARENTES COLATERAIS. ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral

[7] **STJ** - REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

reflexo ou em ricochete." (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017) 2. Agravo interno desprovido." ([8]).

Nesse contexto resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pelo autor original, razão pela qual fixo o valor da indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente adequado à gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, considerando ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas.

O valor fixado deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data desta sentença, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos termos da jurisprudência do STJ (Recurso Especial nº 903258/RS), o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais deve ser a partir da fixação do valor da indenização.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

II.III – DANOS MATERIAIS

A parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente aos custos necessários para o deslocamento de ambulância do hospital PRONCOR para a sua residência, após a alta hospitalar, cujo valor foi impugnado de

[8] **STJ** - AgInt no AREsp 1290597/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

forma genérica pela requerida.

Nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, ***"Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)".***

Logo, por decorrência do princípio da concentração da defesa na contestação, a legislação processual incumbe ao réu o ônus de impugnar especificamente os fatos alegados na petição inicial, ou seja, deve refutar todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de torná-los incontroversos.

Dessa maneira, ante a ausência de impugnação específica do valor relacionado na petição inicial pela parte requerida, bem como considerando que às fls. 25/26 foram juntados comprovante de pagamento e nota fiscal da referida despesa, a reparação deve ser correspondente ao valor requerido na inicial, tal seja, **R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).**

Logo, o pedido de dano material contido na inicial deve ser julgado procedente.

O valor fixado a título de dano material deverá ser atualizado pela variação do IGPM-FGV, desde a data do desembolso, com fim de preservar-se ante a espiral inflacionária.

Observo que a atualização monetária não constitui um *plus* no débito, mas mera recomposição de valores ante à espiral inflacionária, sendo adequada a utilização do IGPM/FGV, posto que se trata de índice que reflete a efetiva variação do custo de vida.

Em relação aos juros moratórios, tal verba é devida a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, visto que a citação é que constitui em mora o devedor.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

O percentual dos juros moratórios deve corresponder a 1% (um por cento) ao mês, visto que se aplica ao caso disposto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (Enunciado 20 do CEJ).

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como arts. 6.º, VIII, e 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para as seguintes finalidades:

1) condenar a requerida em fornecer/custear o tratamento com uso contínuo do aparelho de ventilação positiva BIPAP SYNCHRONY e, por consequência, ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência de fls. 252/254, ressalvando sua abrangência até a data do óbito; e

2) condenar a requerida no pagamento de indenização por dano moral à parte autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pela variação do IGPM-FGV desde a data desta sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também desde a data desta sentença; e

3) condenar a requerida no pagamento de indenização por dano material à parte autora no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), cujo valor deverá ser acrescida de correção monetária pelo IGPM-FGV desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e dos vários atos processuais praticados, fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º, I a IV, do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 17/06/2024 às 11:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836634-56.2017.8.12.0001 e código InadaPAK.